

1500928-37.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500928-37.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500928-37.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MONIQUE TOMIKO DOS REIS HIGASHI SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

MONIQUE TOMIKO DOS REIS HIGASHI SANTOS foi denunciada por incursão no caput do art. 33 e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material.

Narra a denúncia que no dia 10 de maio de 2022, por volta das 11h20min, na Rua Antônio Costa Júnior, 187, Jardim Itaussu, nesta cidade de Mauá, a denunciada guardava/tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 invólucro plástico contendo Cocaína, com massa líquida de 2.361,7 gramas e 01 invólucro plástico contendo Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com massa líquida de 3.435,6 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme imagens de fls. 33-7, laudo de constatação de fls. 30-2 e exame toxicológico de fls. 70-2.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, a denunciada se associou a outra pessoa com o fim de praticar o narcotráfico.

Recebida a denúncia, a ré foi citada (fl. 167) e apresentou resposta à acusação (fls.169-70).

As testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, interrogou-se a ré.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação penal, enquanto a Defesa requer a nulidade da prova produzida e a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime penitenciário inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede em parte a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletim de ocorrência (fls. 03-6), auto de exibição e apreensão (fls. 25-6), laudo de constatação (fls. 30-2), fotos (fls.33-7), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 70-2 e 129-34), laudo pericial do local (fls.95-104), além da prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogada, em solo policial (fl. 11), a ré permaneceu em silêncio. Em juízo, disse que conheceu um rapaz pelo facebook há uma semana, estavam na casa de um amigo dele, próximo ao local, e o rapaz a chamou para ficarem na casa, local dos fatos. Quando os policiais chegaram, o rapaz tinha saído para comprar pão e estava dormindo no colchão. Disse que não viu máquina e drogas no local. Os policiais a levaram no quarto, que estava trancado com as drogas (mídia digital).

Sua versão, contraditória, não merece credibilidade, diante dos depoimentos firmes e seguros dos policiais militares.

O policial militar Igor, na fase administrativa (fls. 08-9), historiou que: (sic) "é policial militar, lotado na Força Tática, e hoje, por volta das 11h20, estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina pelo bairro Itaussu, nesta cidade, quando ao acessar a rua Antônio Costa Júnior observaram, a cerca de vinte metros de distância, um indivíduo de cor parda, demais características ignoradas, que ao perceber a presença policial correu em direção à residência nº 187 aparentemente abandonada e sem muros. O depoente e seu parceiro desembarcaram da viatura e foram atrás do suspeito desconhecido, porém ele conseguiu fugir para o interior de uma mata situada nos fundos da residência. Segundo o depoente, ao passar ao lado da residência em questão, que não tem muros, observaram pela janela do quarto, que estava aberta, a existência de uma máquina empacotadora e no chão diversos sacos aparentemente com drogas, do tipo cocaína e maconha, já embaladas, alguns frascos contendo lança-perfume, embalagens vazias para acondicionar drogas e utensílios, tratando-se, portanto, de um laboratório clandestino para preparação e envasamento de drogas. Diante de tal constatação, ingressaram no imóvel, cuja porta estava apenas encostada, e ao realizar uma varredura localizaram somente uma mulher no quarto ao lado em que estavam as drogas e demais objetos e ao inquiri-la acerca do que fazia naquele local, ela respondeu que se chama Monique Tomiko dos Reis Higashi e mora no imóvel com seu namorado, cuja qualificação não quis revelar, que é o responsável pelo material ali encontrado destinado a abastecer as 'biqueiras' do jardim Canadá, nesta cidade. O depoente e seu parceiro prosseguiram com a varredura

interna e localizaram ainda, além daquelas drogas e apetrechos, um caderno com anotações manuscritas características da contabilidade do tráfico e o telefone celular de Monique, e nos fundos do imóvel, em uma área aberta com acesso à mata por onde o suspeito fugiu, encontraram dois buracos cavados no chão para esconder drogas, porém estavam vazios".

No mesmo sentido o depoimento do policial Gabriel (fl.10).

Sob o contraditório, o policial militar Igor disse que viram um indivíduo na entrada de um terreno, que saiu correndo ao perceber a presença policial. Desembarcaram, o réu correu pela construção que tinha no local e se evadiu pelo fundo do terreno. Ao retornarem para a viatura, a construção tinha algumas janelas abertas e viram uma máquina de empacotar entorpecentes, drogas empacotadas no chão e forte odor de produto químico. Deram a volta na casa, empurraram a porta, que estava aberta, e viram a acusada no local. A ré autorizou a entrada e disse que as drogas eram do namorado. A casa não tinha condições de ser habitada, era uma construção abandonada. Dentro de um dos cômodos tinha um colchão e algumas roupas velhas. Tinha armário velho caído ao chão, aparentemente uma casa abandonada. Não lembra se tinha fogão (mídia digital).

Em juízo, o policial Gabriel acrescentou que a acusada informou que ninguém morava no local. Não lembra de ter visto móveis na casa, viu só um colchão e roupas velhas (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Descabida a alegação da Defesa quanto à ilegalidade na perseguição do rapaz que estava na entrada do terreno, uma vez que os policiais responsáveis pela abordagem da ré, afirmaram ter visualizado um indivíduo na entrada de um terreno, que saiu correndo pela construção que tinha no local, ao perceber a presença policial, e fugiu pelo fundo do terreno, de forma que justificada as fundadas razões para a sua perseguição.

Também não houve invasão de domicílio.

Os policiais militares afirmaram que a casa não tinha condições de ser habitada, era uma construção abandonada. No mais, ainda que assim não fosse, há nos autos elementos aptos a indicar que havia fortes indícios da existência de entorpecentes no interior da casa em questão. Os policiais afirmaram que ao retornarem da perseguição do indivíduo que estava em frente ao terreno e correu pela construção, viram pelas janelas uma máquina de empacotar, drogas empacotadas no chão e forte odor de produto químico.

Cumpre relembrar que o narcotráfico é crime permanente, permitindo-se à autoridade

policial, a partir da fundada suspeita, ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, sem mandado judicial ou permissão do morador (Ap. 0000990-27.2014.8.03.0006 -AP, Câmara Única, rel. Carlos Tork, 21.06.2016, v.u.).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS [...] DOMICÍLIO - VIOLAÇÃO - FLAGRANTE - ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ALCANCE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, a ocorrência, no momento, de crime, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de autorização judicial. [...] (HC 159017, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019 - grifo nosso).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ENTRADA AUTORIZADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso em exame, porém, conforme se infere do acórdão impugnado do TJGO, após o recebimento de denúncia anônima sobre o intenso tráfico de drogas naquele endereço, os policiais foram em diligência averiguar o caso, e ao chegarem no local "a entrada na casa teria sido autorizada pelos moradores." A versão é a mesma contida no auto de prisão em flagrante, das declarações prestadas pelos agentes públicos. A ação policial logrou êxito na apreensão de 2 porções de maconha pesando 1,055 kg e 3 de crack pesando 0,554, além de uma balança, celular e um veículo Hyundai HB20, vermelho, placa OMT-3218, com restrição de furto e roubo. 4. São válidas as provas colhidas mediante o ingresso autorizado dos policiais no domicílio do agravante. Julgados nesse sentido. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 111.760/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019 - grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 2. No julgamento do RE n. 603.616, Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada na associação das seguintes circunstâncias narradas nos autos: I) tratar-se de acusado foragido da justiça em outra ação penal também por delito de tráfico de drogas e previamente reconhecido; II) policiais já estavam em diligência para apurar informações recebidas sobre a comercialização de entorpecentes pelo paciente utilizando determinado veículo; e III) fuga do acusado para dentro de casa após a abordagem policial, tentando escapar pela parte de trás

da residência, sendo preso neste momento diante do certo realizado pelos policiais que, após, encontraram mais de 9kg de cocaína na residência. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 615.563/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021 - grifo nosso).

Não bastasse, em recente decisão da Suprema Corte no RE 1.342.077, o Ministro Alexandre de Moraes reconheceu a prescindibilidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais:

"Incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE. Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa) [...]."

Além disso, no laudo pericial de fls.95-104 constou que o imóvel era isolado internamente por portas de madeira (frente e fundos) sem sistema de fechamento. Descabida assim, a alegação da Defesa de que a ré não tinha participação no tráfico porque as drogas estariam em um cômodo trancado.

No mais, a farta quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a forma de acondicionamento, além do caderno com anotações do tráfico de drogas e diversos materiais relacionados ao armazenamento, manipulação e fracionamento de entorpecentes apreendidos no imóvel (fls.95-104), são elementos suficientes de que as drogas eram destinadas ao consumo de terceiros.

Todavia, há que se afastar o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, pois o delito em tela exige para sua configuração a união estável com a finalidade de praticar crimes. Caracteriza-se a associação pela permanência e estabilidade. Não há nenhum elemento nos autos, colhido sob o crivo do contraditório, que aponte para tais requisitos.

Dessa forma, entende-se que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, diante da elevada quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas -3.500 gramas de cocaína, 3.950 gramas de maconha e 83 mililitros de lança-perfume-, fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta do agente (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido).

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última etapa, não deve incidir a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Diante das circunstâncias do delito, incompatíveis com traficantes "ocasionais" - a ré foi presa em flagrante, em imóvel onde continha drogas (notadamente cocaína, de alto poder vulnerante), caderno contendo anotações de contabilidade do tráfico e diversos materiais relacionados ao armazenamento, manipulação e fracionamento de entorpecentes (máquina dosadora/empacotadora automática de drogas, balanças digitais, ralador, bacias, pratos, estilete, lâmina, peneiras, facas, martelo de borracha, galões acondicionando substância líquida com etiqueta de identificação "álcool 96ºGL", caixa acondicionando material sólido com inscrições "bicarbonato de sódio") e não comprovou de forma mínima o exercício de atividade lícita- parece-me claro o acentuado envolvimento da acusada no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Além disso, a ré possui condenação em outro processo pela prática do tráfico de drogas (cert. fls.165-6 - proc 1502010-74.2020).

Sobre o potencial lesivo da cocaína apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense - Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

Quanto ao afastamento da causa de diminuição, destaca-se julgados do e. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE (ART. 44, I, CP). INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZ DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Como destacado na decisão agravada, cabe às instâncias ordinárias, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las, na primeira fase, para exasperar a pena-base ou, na terceira fase, para graduar o redutor do tráfico privilegiado, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem. No ponto, importa destacar que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base no patamar mínimo previsto em lei. III - A quantidade, diversidade e nocividade das drogas apreendidas podem ser utilizada para fixação do regime mais gravoso do que o quantum de pena aplicada, por configurar maior gravidade na conduta, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. Precedentes. IV - Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, não há que se falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 475.345/SP, relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019.) g.n.

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça" (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.431.091 - SP (2014/0015576-0), RELATOR : MINISTRO FÉLIX FISCHER, j. 14 de dezembro de 2016). g.n.

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. AÇÕES PENAIIS EM CURSO. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. (...). - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que a jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EResp n. 1.431.091/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, DJe 1º/2/2017). (...). (HABEAS CORPUS Nº 536.141 - SP (2019/0290756-9), RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, 17 de outubro de 2019)

No mesmo sentido o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"(...) Embora LEONARDO seja tecnicamente primário, esse apelante ostenta outra condenação não definitiva por tráfico, delito praticado em março de 2021, cerca de cinco meses antes, portanto, do crime objeto deste feito. E, no tocante a essa condenação Processo nº 1500640-26.2021.8.26.0540 , cuja sentença foi proferida em 12 de agosto de 2021, o apelo defensivo, em julgamento realizado no dia 29 de setembro, restou desprovido pela Colenda 14ª Câmara Criminal, assim como os embargos declaratórios opostos pela Defesa também foram rejeitados em 19 de novembro do mesmo ano. Pendente de prelibação a ser efetuada pelo eminente Desembargador Presidente da Seção Criminal, o recurso especial, no caso dos autos,

não impede seja a condenação por tráfico levada em consideração para afastar a pretendida causa de diminuição do privilégio em favor de LEONARDO. Trata-se, como os comparsas, de traficante não eventual, vinculado, certamente, a grupo minimamente estruturado, embora não comprovado por elementos concretos a associação de modo estável e permanente com outros indivíduos. A diversidade e a quantidade de entorpecente, para além dos registros criminais, evidenciam a habitualidade com que praticava a traficância. A conduta praticada pelos três acusados, bem como os registros criminais que ostentam, revela efetivo perigo à sociedade, denotando exacerbada culpabilidade, condição que desautoriza o reconhecimento do privilégio, benefício destinado a traficante não contumaz, de menor envergadura. (Apelação Criminal nº 1501963-66.2021.8.26.0540, Des. Rel. OTÁVIO DE ALMEIDA, j. 13.06.22). G.N.

"(...) Frise-se, por oportuno, a inaplicabilidade do redutor especial inserto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tal como decido monocraticamente. Como cediço, ao editar o mencionado dispositivo legal, o legislador objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, conseqüentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Em outras palavras, para a situação do mercador novato de pequena expressão, o chamado "traficante de primeira viagem", como se pode qualificar aquele que possui "estoque" diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o próprio vício é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu maior rigor punitivo. Nessa quadra, a par da primariedade, os elementos angariados aos autos demonstram, à sociedade, que as circunstâncias fáticas, concretamente recolhidas no curso das investigações e comprovadas em Juízo, são inconciliáveis com a traficância ocasional. Isso porque, o réu foi flagrado transportando e guardando exacerbada quantidade de entorpecentes (247 porções de maconha, 406 pinos de cocaína e 438 porções de crack), com naturezas extremamente destrutivas e nocivas, suficiente a atingir inúmeros usuários, de sorte a evidenciar a dedicação às atividades criminosas (narcotraficância). Nem se cogite a ocorrência do intolerável bis in idem, pois a quantidade dos entorpecentes, muito embora sopesada na primeira fase da dosimetria penal, não foi aqui considerada de forma isolada para o afastamento do benefício legal, ao contrário, as circunstâncias fáticas do flagrante policial (o que inclui natureza, quantidade e diversidade dos entorpecentes, situação de fuga à abordagem, em ponto com denúncias reiteradas da traficância), em conjunto, evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa, sendo absolutamente implausível o reconhecimento do privilégio." (Apelação Criminal nº 1500603-96.2021.8.26.0540, Rel. Des. CLÁUDIA FONSECA FANUCCHI, j. 13 de dezembro de 2021). g.n

Ainda sobre o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06:

"(...) Cabe salientar que 'a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas', para os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC nº 94.806, relatora Ministra Cármen Lúcia). Na realidade, a qualificação do agente como pessoa dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal), não se exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização da repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC nº 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante salientado pelo Ministro Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu voto, 'os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'. Deveras, na interpretação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, há que se atentar para

o elemento teleológico, na dicção do artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 12 edição, pp. 88/89; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2ª edição, pp. 430/431), vale dizer, no sentido de que o escopo da lei foi de beneficiar com uma sensível redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente para a ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não é, decididamente, a situação dos réus." (TJSP, Ap nº 1501840-05.2020.8.26.0540, Des. Rel. LAERTE MARRONE, j. 28.04.21).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...]" (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugénio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da

conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

Estabiliza-se, assim, as sanções em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica da ré.

Anote-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando a quantidade e diversidade das drogas, assim como o alto potencial lesivo da cocaína para saúde pública, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes. Ordem denegada." (STF - HC 119.515/AC - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 03.12. - DJU 10.12.13)

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR a ré MONIQUE TOMIKO DOS REIS HIGASHI SANTOS, qualificada nos autos, a cumprir pena de 07 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e ABSOLVÊ-LA da imputação de ofensa ao art. 35 do mesmo diploma, com espeque no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Denego à ré o apelo em liberdade, mantidos os fundamentos da custódia cautelar (fls.124-5).

Transitada em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, nos termos dos artigos 123 do Código de Processo Penal e 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, os bens apreendidos ficarão disponíveis para os interessados, desde que comprovada a propriedade, pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, fica determinado seu perdimento, para posterior alienação em leilão ou destruição, se o caso. Quanto à contraprova das drogas, determino sua destruição, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA